

1500140-90.2022.8.26.0550

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo.

Tal entendimento decorreu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida Ulysses Guimarães, 2800 (antigo 506), Rio Claro-SP - cep 13506-547

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500140-90.2022.8.26.0550 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500140-90.2022.8.26.0550

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2076261/2022 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 23714075 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO,

1660/22/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2076261 - DEL.INV.GER. RIO CLARO,

1660/22/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALISSON DE SOUZA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

ALISSON DE SOUZA e GUILHERME CASAGRANDE, qualificados no inquérito, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c/c as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque, no dia 18 de março de 2022, por volta das 18:40 horas, na Estrada dos Costas, Condomínio Itália, Bloco nº 06, apartamento nº 102, Jardim das Nações, neste município e comarca, ALISSON trazia consigo, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, 03 (três) invólucros contendo a substância entorpecente denominada tetraidrocanabinol, enquanto GUILHERME, com quem agia em concurso e com identidade de propósitos, trazia consigo, com intuito

mercantil, para consumo de terceiros, 03 (três) invólucros contendo a substância entorpecente denominada tetraidrocanabinol, e ainda guardavam e tinham em depósito, com intuito mercantil, para consumo de terceiros outros 40 (quarenta) invólucros contendo a substância entorpecente denominada tetraidrocanabinol, totalizando com aqueles peso líquido aproximado de 119 gramas e 72 (setenta e dois) microtubos plásticos do tipo eppendorf contendo substância entorpecente denominada cocaína, totalizando peso líquido aproximado de 17,1 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19 e laudo de constatação de fls. 21/28, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 157/158).

Regularmente notificados (fls. 205, 207), seguiram-se oferecimento de defesas preliminares em favor dos Acusados (fls. 211/215, 249/256, 264/279), sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 19 de julho de 2022 (fls. 300/310).

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e uma de defesa, com posterior interrogatório dos Acusados (fls. 384/385).

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação dos Acusados, nos termos da denúncia, com fixação das penas-bases nos mínimos legais, a ser majorada para GUILHERME em decorrência da recidiva, com o afastamento do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, devendo a pena resultante ser cumprida em regime prisional inicial fechado; e, em relação a ALISSON, reclamou a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, diante da primariedade, incidindo a pena de perdimento sobre os valores apreendidos, porque decorrentes da atividade ilícita (fls. 384/385).

Já a ilustre Defensora do acusado ALISSON, inicialmente entendendo não constituir o fato infração penal, requereu a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, afirmando ser o Acusado usuário de entorpecente, reclamou a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Tóxicos. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com fixação de regime prisional diverso do fechado, possibilitando a interposição de eventual recurso em liberdade (fls. 384/385).

A i. Defesa de GUILHERME, a sua vez, requereu preliminarmente a declaração de nulidade das provas que aduziu terem sido colhidas de maneira ilícita em razão da busca domiciliar ilegal, nos termos do que disposto no artigo 157 do Código de Processo Penal. No mérito, aduzindo insuficiente a prova produzida, reclamou a absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, requereu seja a pena base fixada no mínimo legal, com a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, fixação de regime prisional diverso do fechado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 386/400).

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se aos Acusados a prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c/c as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque, ALISSON trazia consigo, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, o entorpecente descrito na denúncia, enquanto GUILHERME, com quem agia em concurso e com identidade de propósitos, trazia consigo, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, outra quantidade de substâncias ilícitas, e ainda guardavam e tinham em depósito, com intuito mercantil, para consumo de terceiros outra quantia de entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 174/175, com resultado positivo para cocaína, identificando-se também em parte da substância apreendida o elemento tetraidrocanabinol, responsável pelos efeitos estupefacientes da maconha.

Sustenta-se que estaria comprometida a apreensão do entorpecente, maculando a materialidade do delito, assim em razão da ilícita abordagem inicial, fundada em denúncia anônima, como também em razão da violação de domicílio.

Entretanto, respeitado o entendimento exposto pela combativa Defensora, consta que Policiais Militares, após receberem informação de um popular de que indivíduos estariam realizando o tráfico ilícito de entorpecentes, dirigiram-se ao local indicado, de onde os Acusado empreenderam fuga até a moradia deles, localizada nas imediações. Como a porta do imóvel se encontrava encostada, foi possível notar que eles tentavam fugir por uma janela, sendo em seguida abordados por outra equipe policial, apreendendo-se em poder deles substância entorpecente, com informação de que havia outra quantidade de substância ilícita no interior do apartamento onde residiam, por isto realizada a busca domiciliar, com efetiva apreensão de entorpecente, além de quantia em dinheiro e balança de precisão, comumente utilizada para pesagem da substância ilícita.

Diante destas circunstâncias, com informação que relacionava o local e os Acusados ao tráfico, onde foram efetivamente encontrados, e de onde empreenderam fuga, posteriormente abordados com entorpecente, reuniram-se elementos que permitiram vislumbrar, desde logo, o estado flagrancial que excepcionava a garantia de inviolabilidade do domicílio, seguindo-se a apreensão das 40 (quarenta) porções da mesma substância, acondicionadas em uma pochete, uma balança de precisão e a importância de R\$ 1.465,00 em dinheiro, como anteriormente dito, seguindo-se a prisão em flagrante.

E a autoria atribuída aos Acusados é certa.

Ouvido em Juízo, o acusado ALISSON negou estivesse vendendo entorpecente, mas apenas o armazenando. Narrou que, no dia dos fatos, um conhecido pediu para que guardasse uma sacola, no interior da qual estava a substância ilícita, guardando-a no interior do guarda-roupa onde estavam seus pertences, inclusive quantia em dinheiro proveniente de seu trabalho na empresa Tigre. Esclareceu que estava temporariamente na moradia de GUILHERME, já que havia se desentendido com a esposa e, enquanto olhava pela janela, avistou os Policiais Militares, momento em que saiu correndo, alertando para que GUILHERME também o fizesse. Afirmou que o coacusado desconhecia a existência de substância entorpecente no local e que prontamente indicou aos Policiais onde a estava armazenando (fls. 384/385).

O Acusado GUILHERME, a sua vez, afirmou que conhecia ALISSON há muito tempo e que na ocasião ele estava se separando da esposa dele, por isto se encontrava temporariamente em sua moradia. No dia dos fatos o coacusado alertou para que saísse correndo, posteriormente pulando a janela do imóvel. Não entendeu o que estava ocorrendo, inclusive imaginou que estivesse pegando fogo em algum lugar, motivo pelo qual também correu. Em seguida, foram abordados pelos Policiais Militares, os quais, posteriormente, adentraram à moradia e apreenderam entorpecente, cuja existência desconhecia, inclusive tendo ALISSON lhe pedido desculpas por armazenar aquela substância ilícita no local. Apesar de terem relatado aos Policiais que não sabia da existência do entorpecente no local, acabou preso em flagrante. Por fim, acrescentou que também desconhecia a origem da balança de precisão apreendida (fls. 384/385).

A versão apresentada pelos Acusados foi contrariada pela prova produzida.

A testemunha Ângelo, Policial Militar, afirmou que estavam em patrulhamento, quando receberam notícia advinda de um popular -- morador do mesmo condomínio onde estavam residindo os Acusados -- de que indivíduos estariam realizando o tráfico ilícito de entorpecentes, fornecendo então detalhes das vestimentas daquelas pessoas, características físicas, bem como a localização onde estariam e a indicação do apartamento deles, número, andar e bloco. No local indicado avistaram os indivíduos, os quais empreenderam fuga para o interior de uma moradia, que estava com a porta encostada, o que permitiu notar quando os Acusados empreenderam fuga por uma janela aos fundos do imóvel -- onde outras equipes policiais os detiveram, apreendendo-se substância entorpecente com cada um deles, os quais afirmaram que havia outra quantidade de entorpecente no interior da moradia. Em busca domiciliar, de fato, localizaram quantia em dinheiro, balança de precisão bem como mais substância entorpecente -- já individualizada para a realização da comercialização. Os Acusados, então, admitiram a prática delitiva (fls. 384/385).

Ouvido em Juízo, o Policial Militar Ronimagson esclareceu que estavam em patrulhamento pela Avenida dos Costas, quando acionados por um transeunte,

informando que no condomínio onde residia, Condomínio Itália, dois indivíduos estavam dedicados ao tráfico ilícito de entorpecentes defronte a um dos blocos, que cuidou-se em especificar. Diante do informado, diligenciaram no local, onde o portão de acesso ao estacionamento estava aberto em razão do grande fluxo de veículos. No pátio do condomínio, avistaram os dois Acusados, os quais empreenderam fuga com a aproximação policial, adentrando em um apartamento. A equipe da qual fazia parte tentou contato com eles naquela moradia e passaram a ouvir barulhos no interior da residência, quando então foram avisados por outros Policiais, que cercavam o local, que haviam abordado os Acusados, após terem pulado uma janela situada aos fundos do imóvel. Em busca pessoal, foram apreendidas porções de maconha em posse de ambos os Acusados, tendo eles admitido que estavam realizando o comércio ilícito, porque estavam desempregados. Indicaram, ademais, que teriam alugado aquele apartamento para o fim de realizar as atividades ilícitas, inclusive estando armazenada outra quantidade de substâncias ilícitas no interior do mesmo, por isto realizada a busca domiciliar, oportunidade em que apreendidas quarenta porções de maconha e setenta e dois microtubos contendo cocaína, além de balança de precisão, aparelho celular e quantia em dinheiro, que eles afirmaram advir do tráfico (fls. 384/385).

Como se tem reiteradamente sustentado, à míngua de elemento que demonstre efetivamente algum abuso, não há se desmerecer o depoimento dos policiais envolvidos na diligência.

A propósito: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54).

Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu). Deste modo, os elementos probatórios produzidos permitem seguro juízo de convicção sobre o armazenamento do entorpecente, apreendido na moradia de GUILHERME, bem como sobre sua destinação mercantil, não apenas em função da quantidade apreendida, como também em razão das circunstâncias relacionadas à apreensão - informação dando conta de que pessoas com as mesmas características físicas e de vestimenta dos acusados, no apartamento por eles ocupado, estavam envolvidos com a mercancia ilícita; início de fuga de ambos os Acusados, inclusive tendo pulado a janela do imóvel; apreensão da balança comumente utilizada para a preparação de entorpecente para comercialização; e a efetiva apreensão de entorpecente.

Por fim, diante da apreensão dos valores na moradia do acusado ALISSON, com indicação de que decorria da venda do entorpecente, possível a incidência da pena de perdimento.

Isto considerado, passo à dosagem das penas.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, diante das circunstâncias pessoais favoráveis, e não sendo expressiva a

quantidade de entorpecente apreendido, possível a fixação da pena base a ambos os Acusados no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em relação a ALISSON:

Deixo de considerar a circunstância atenuante da confissão espontânea, porque já fixada a pena-base no mínimo legal (Súmula 231, STJ).

A pena-base cominada a ele deve ser reduzida em função do que disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Este dispositivo legal cuida da possibilidade de operar-se a redução da pena, quando se tratar de réu primário, de bons antecedentes, não integrante de organização criminosa e que não esteja dedicado ao comércio ilícito. O acusado é primário, não havendo indicação suficiente de que estivesse já dedicado à atividade criminosa, não sendo, como dito, expressiva a quantidade de entorpecente apreendido, de tal modo que deve a pena-base ser reduzida em 2/3 (dois terços), totalizando 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do Acusado.

Diante da operada redução da pena inicialmente cominada, caracterizando a figura do tráfico privilegiado, devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento que se consagrou no Colendo Supremo Tribunal Federal e Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Sobre isto, revendo entendimento consolidado anteriormente, com consequente cancelamento da Súmula nº 512, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que o tráfico de entorpecente, em sua forma privilegiada, não tem natureza hedionda.

Segundo o decidido, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no artigo 33 caput e §1º, da Lei 11.343/06 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria "contornos mais benignos, menos graves, notadamente porque são relevantes o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa".

Além disto, destacou-se que, apesar da vedação constitucional e legal da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo.

Tal entendimento decorreu do posicionamento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em acórdão relatado pela Ministra Carmem Lúcia, observando-se que a decisão do legislador fora no sentido de que o agente deveria receber tratamento distinto daqueles sobre os quais recairia o alto juízo de censura e de punição pelo tráfico de drogas e de que as circunstâncias legais do privilégio demonstrariam o menor juízo de reprovação e, em consequência de punição (HC 118.533/MS, 23/06/2016).

Acrescentou-se que, nem toda transação ilícita com drogas deve necessariamente submeter-se ao regime dos crimes hediondos, como a conduta de quem oferece droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem (art. 33, §3º, Lei 11.343/06), bem como a de quem, de forma episódica, pratica o denominado tráfico privilegiado (art. 33 §4º, Lei 11.343/06).

Nesta linha de raciocínio, consignou-se que o artigo 44 da Lei de Tóxicos, ao estabelecer que os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 a 37 da Lei 11.343/06 "são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos", conferiu ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º), tratamento especial ao que o legislador atribuiu ao caput e ao §1º do artigo 33, a reforçar a tese de que não se trata de delito hediondo.

Ainda segundo o que decidido, o conceito de hediondez é de todo incompatível ao de privilégio, conforme há muito vem decidindo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no que diz com o homicídio qualificado-privilegiado, não se lhe aplicando o disposto na Lei 8072/90, afastando, portanto, a natureza hedionda.

Concluiu-se que o julgamento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ainda

que por seu Órgão Pleno, não tem efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, nos termos do artigo 927, §4º, do Código de Processo Civil, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito daquele Egrégio Tribunal Superior, entendeu-se ser necessária a revisão da questão, com a determinação da revisão do entendimento anterior, estabelecendo-se a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada não é crime equiparado a hediondo.

Assim, cumpre seja a pena privativa substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena cominada, a ser dirimida em execução, como também por uma pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo.

Em relação ao acusado GUILHERME:

A pena-base cominada deve ser agravada em 1/6 (um sexto), por conta da recidiva (fls. 59), totalizando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Deixo de reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, não apenas em função da recidiva do Acusado, mas também diante da condenação ostentada também por tráfico, o que juntamente com as circunstâncias indicadas por aqui revelam inequívoca dedicação à atividade criminosa, não se tratando o Acusado de "neófito" que fizesse jus ao chamado "tráfico privilegiado".

O valor das pecuniárias fica fixado no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica dos Acusados.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, em consequência:

(i) com fundamento no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, I, do Código Penal, CONDENO o acusado GUILHERME CASAGRANDE à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, diante da situação econômica do acusado, corrigido desde a época do fato; e

(ii) com fundamento no artigo 33, "caput", c.c. §4º da Lei nº 11.343/06, CONDENO o acusado ALISSON DE SOUZA à pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, a ser dirimida em execução, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigido desde a época do fato, como também de pena pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo. Em caso de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, esta deverá ser cumprida em regime prisional inicial aberto. Diante da pena cominada a ALISSON, expeça-se alvará de soltura clausulado em favor dele.

Sobre a quantia apreendida, deve incidir a pena de perdimento em favor da União, porque decorrente da ação ilícita, nos termos do disposto no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e artigo 63, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena de GUILHERME, deve ser considerada a recidiva e a natureza hedionda do delito, por equiparação, atendendo comando constitucional (art. 5º, XLIII, CF), dispondo o artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07, que deve a pena ser cumprida inicialmente em regime prisional fechado, introduzindo a progressividade, a fim de sanar vício da redação inicial que determinava o integral cumprimento da sanção em regime prisional fechado, o que atentaria contra o princípio da individualização da pena.

Não se ignora que, ainda esta alteração, com disposição de início em regime fechado, foi também considerada inconstitucional, em caráter incidenter tantum, no HC nº 111.464/ES, sendo Relator o Ministro Dias Toffoli, por maioria devotos, entendendo-se padecer do mesmo vício de violação ao princípio da individualização da pena, devendo ser fixado o regime prisional, mesmo em se tratando de delitos hediondos e equiparados, na forma do artigo 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

Nada obstante a autoridade da mencionada decisão, promanada do Pretório Excelso, em

controle difuso, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade, e considerando a controvérsia que marca a questão, até mesmo no âmbito da Suprema Corte, já que a decisão foi tomada por maioria de votos, possível dizer, com a mais elevada vênua, que em função do comando previsto no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, cuidou o legislador infraconstitucional em estabelecer tratamento mais rigoroso para o cumprimento da pena de alguns delitos (hediondos e equiparados) dada a maior gravidade da violação aos bens juridicamente protegidos, por isto se estabelecendo no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a alteração dada pela Lei nº 11.464/07, que a pena seria cumprida em regime prisional inicial fechado.

Não se entende, renovada a vênua, tenha a disposição legal violado o princípio da individualização da pena, porquanto, não obstante a limitação ao regime inicial mais gravoso, como ocorre em situações outras, dada a valoração legitimamente exercida pela atividade legislativa, tendo como fonte o anseio de se reprovar de forma distinta ações delitivas que causam maior perturbação ao meio social, não se tem por interditada a progressividade no cumprimento da pena, tampouco os benefícios do livramento condicional e a remissão, o que assegura a individualização da sanção, sem descurar de suas funções retributivas e preventivas, além de ressocializadoras.

Como se tem objetado, se o regime inicial obrigatoriamente fechado é inconstitucional, por conta de critérios qualitativos (crimes hediondos e equiparados), também o seria pelo critério quantitativo da regra prevista no artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, que prevê obrigatoriamente regime prisional inicial fechado no caso de pena superior a 8 (oito) anos.

Além disto, submetendo a individualização da pena em casos de delito hediondo ou equiparado tão somente às regras gerais previstas no artigo 33, §2º, do Código Penal, estar-se-ia retirando eficácia do comando inserto na Constituição Federal que determinou a adoção de tratamento diferenciado mais rigoroso nestas hipóteses (cf. art. 5º, LXIII, CF).

Deste modo, a pena cominada ao acusado GUILHERME deverá ser inicialmente cumprida em regime prisional fechado, isto também decorrendo da recidiva, não se lhe facultando a interposição de recurso em liberdade, já que persistem os fundamentos que determinaram a prisão cautelar, potencializados pela sentença condenatória, sem prejuízo de eventual progressão em sede de execução provisória.

Sobre isto: "O direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva. A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência (Súmula nº 9, do STJ)" (HC nº 86907/RS, Rel. Min. Felix Fisher, DJU. 14.04.2008, p.1).

E, especificamente aqui, "a apelação em liberdade prevista no art. 59 da Lei nº 11.343/06 pressupõe a cumulação dos pressupostos da primariedade e da inexistência de antecedentes com o fato de ter o réu respondido em liberdade à ação penal, tanto pela inocorrência de prisão oriunda de flagrante delito quanto pela inexistência de decreto de prisão preventiva" (HC Agr. 94.521/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 1º.08.2008).

E, por fim: "o agente que responde a todo o processo por tráfico ilícito de entorpecente preso não tem o direito de aguardar o recurso interposto pelo órgão Ministerial em liberdade, mesmo tendo a sentença contra si prolatada substituído a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e serviços à comunidade, eis que a efetividade imediata da pena substitutiva, configuraria em execução provisória" (TJSP, HC 387.079-3/4, 5ª Câmara, Rel. Des. Gomes de Amorim, v.u., RT807/605, apud RENATO Marcão, Tóxicos, 4ª ed. p.527).

E diante do quantum da pena aplicada, não incide as disposições previstas no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal.

Recomende-se o acusado GUILHERME na prisão em que se encontra e, oportunamente, promova-se o registro das condenações definitivas no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA